

1500137-77.2021.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Alega que o propósito de praticar tráfico de drogas restou devidamente evidenciado pelo local dos fatos ser ponto conhecido de venda de drogas, pela movimentação típica de tráfico de entorpecentes visualizada pelos policiais, pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pela apreensão de dinheiro e pela fuga do acusado. Requer o aumento de pena na primeira fase, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500137-77.2021.8.26.0613 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500137-77.2021.8.26.0613

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108402/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 17454549 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 562/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2108402 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HENRIQUE EFIGENIO FONSECA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de Carlos Henrique Efigenio Fonseca, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, eis que no dia 20 de Abril de 2021, por volta das 1h horas, na Rua das Mangueiras, Carlos Cassuci, nesta cidade e comarca, trazia consigo 10 (dez) porções de maconha, pesando 32,96 gramas, 02 (dois) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 2,13 gramas, e 29 (vinte e

nove) porções de crack, pesando 6,40 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia de págs. 103/104 veio amparada no Inquérito Policial – Prisão em Flagrante – de págs. 01/86.

Prisão em flagrante substituída por cautelares diversas da prisão, conforme decisão de págs. 67/70.

O réu foi devidamente citado (págs. 111), e apresentou defesa prévia (págs. 107/109), requerendo a improcedência da pretensão ministerial. Não devendo haver inversão do ônus probatório. Por fim, requer a rejeição da denúncia.

A denúncia foi recebida aos 19 de maio de 2021, oportunidade em que fora designada audiência de instrução (págs. 114/116).

Aos 17 de agosto de 2021 foi realizada audiência com a oitiva das testemunhas arroladas e interrogatório do réu, conforme termo de pgs. 153/154.

Na fase do art. 402 do CPP foi requerida a juntada de novos documentos – pgs. 154.

Sobrevieram os documentos nas pgs. 155/157.

Memoriais ministeriais nas pgs. 176/180 requerendo a procedência da ação penal. Após exposição da prova oral coligida, sustenta que a versão do réu está isolada e nada desabona as palavras dos policiais. Alega que o propósito de praticar tráfico de drogas restou devidamente evidenciado pelo local dos fatos ser ponto conhecido de venda de drogas, pela movimentação típica de tráfico de entorpecentes visualizada pelos policiais, pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pela apreensão de dinheiro e pela fuga do acusado. Requer o aumento de pena na primeira fase, diante da variedade de drogas. Não se opõe à minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e reputa possível a fixação de regime aberto.

A defesa, por sua vez, manifestou-se nas pgs. 188/192 alegando que não há falar-se em delito de traficância. Reputa frágeis os depoimentos dos policiais e requer a absolvição na forma dos incisos V e VII do art. 386 do CPP. Invoca o benefício da dúvida, pois o réu não foi surpreendido em atividade de traficância e muito menos com qualquer outro elemento que levasse a crer ser o denunciado traficante. Alternativamente, pugna pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, fixando-se a pena no mínimo legal. Requer o direito de apelar em liberdade.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 10/11), fotos de pág. 14/16, auto de constatação

preliminar de págs. 12/13, requisição de IC de págs. 24. Da mesma forma, a materialidade decorre dos laudos periciais de pgs. 144/152.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

1.2 -) Das provas da autoria.

A testemunha e policial civil João Carlos Mancuso, em juízo, afirmou ser investigador de polícia. No dia dos fatos, estava em investigação pelo bairro Cassucci, local conhecido como "predinhos do profast". Trata-se de local de intenso tráfico de drogas. A polícia estava em duas viaturas descaracterizadas. Em campanha, viu Carlos na prática de tráfico. Pessoas compravam e saíam. Ele entregava e recebia dinheiro. O réu foi visto na prática de ato de comércio. Quando foi ser abordado, ele empreendeu fuga e arremessou um pacote. Era um pacote plástico, uma sacola. Com ele, havia R\$ 77,00 em dinheiro, em notas miúdas e diversas, e uma porção a granel de maconha. No pacote dispensado pelo réu, encontravam-se 9 porções de maconha, fracionadas e embaladas para a venda, 2 eppendorfs de cocaína e 39 pedras de crack. As maconhas do pacote tinham embalagem semelhante daquela encontrada junto ao réu. Foi dada voz de prisão ao réu seguida de condução à delegacia. Florence e outros dois policiais estavam no apoio. No momento, foi visualizado o réu vendendo. Também foram vistos compradores. Vendendo tinha somente o réu. O réu empreendeu fuga. Os compradores não foram abordados. O alvo era o vendedor. Ele era visto constantemente nos "predinhos do profast" por volta de um mês. Seus familiares comparecem à delegacia. Ele só não foi preso antes por ter fugido. Não sabe de outras ocorrências envolvendo o réu.

De modo semelhante, manifestou-se Florence Ribeiro Gallego Gomes em solo policial (fl.3). Vale transcrever o teor do depoimento em fase inquisitiva: " Que é a policial civil chefe do setor de investigações gerais desta unidade, e, nesta tarde, em diligências por esta circunscrição policial, ao passar por um local conhecido pelo comércio ilícito de drogas, avistou um indivíduo caminhando pela via pública em poder de uma sacola plástica, aproximando para abordagem. O suspeito, ao perceber que seria abordado, passou a correr em sentido oposto, dispensando a sacola no chão, procedendo ao seu acompanhamento alcançando-o logo adiante. Ao proceder a revista pessoal do suspeito, identificado como o autuado CARLOS HENRIQUE EFIGÊNIO FONSECA, localizou em seu poder uma porção a granel de substância semelhante a maconha e a quantia de R\$77,00 (setenta e sete reais), em espécie. No interior da sacola dispensada momentos antes, foram localizados mais 09 (nove) porções de substância semelhante a maconha, 02 (dois) microtubos contendo substância que aparenta cocaína e 39 (trinta e nove) pedras de substância similar a crack. Diante de todo o ocorrido, proferiu voz de prisão em flagrante delito ao indivíduo detido, providenciando sua condução a esta unidade policial para as medidas cabíveis."

O réu, Carlos Henrique Efigenio Fonseca, em seu interrogatório, em juízo, contou trabalhar com verdura na roça, auferindo por volta de R\$ 1.200,00 reais no mês. Nunca teve problemas com a justiça. Não é verdadeira a acusação. É usuário de drogas. No dia dos fatos, só foi comprar maconha. Não estava com a sacola. Não conhece os policiais. Não sabe por qual motivo eles o incriminariam. Sua namorada mora lá nos prédios. Ficava lá alguns dias na semana e, por isso, levava algumas roupas em sacola. Pode ser que estava com uma sacola com cuecas nas mãos. Sua sogra pegou essa sacola, que caiu de sua mão quando começou a correr. Sua sogra e sua namorada estavam do seu lado. Tinham outras pessoas adquirindo drogas. Tinham duas, três pessoas vendendo drogas. Costumava ir naquele local comprar maconha. Estava com maconha e 77 reais em dinheiro. O dinheiro era proveniente da roça.

2 -) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos.

Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que contemplar violação ao princípio da igualdade tratando diversamente o valor de uma testemunha por sua profissão, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada." (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a "lei do silêncio", extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

Ambos os policiais foram uníssomos em dizer que o réu estava na posse da sacola dispensada com variedade de drogas e diversas porções fracionadas, fatos ocorridos em local amplamente conhecido como ponto de venda de drogas nesta cidade, qual seja, "os predinhos do Profast".

O policial João Carlos Mancuso foi além. Declarou que viu o réu vendendo drogas, diretamente, antes de ser abordado.

Nada faz crer que os policiais pudessem ter consigo 10 (dez) porções de maconha, pesando 32,96 gramas, 02 (dois) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 2,13 gramas, e 39 (trinta e nove) porções de crack, pesando 6,40 gramas, para indevidamente "forjar" cidadãos, colocando suas carreiras em risco a fim de aprisionar pessoas com as quais não mantêm qualquer desafeto ou problema pessoal.

O réu, a seu turno, não declarou qualquer inimizade ou explanou situações concretas que pudessem indicar que os policiais em questão estariam simplesmente a elucubrar versão incriminadora para lhe prejudicar. Sendo assim, não se pode presumir que os policiais estejam imbuídos por sentimentos subalternos dignos de censura ao engendrar versão incriminadora contra cidadão que sabem ser inocente.

Nada sugere qualquer equívoco dos policiais em relação à dispensa da sacola plástica, durante a fuga. O réu foi diretamente visualizado desfazendo-se dos entorpecentes, conforme a prova colhida. Inexistem provas em sentido contrário, capazes de suscitar alguma dúvida fundada a respeito da pertinência subjetiva passiva da ação penal.

Conforme artigo 156 do CPP "A prova da alegação incumbe a quem a fizer [...]". Portanto, não se trata de qualquer inversão do ônus da prova, mas sim de aplicação da dinâmica probatória imposta pelo devido processo legal.

Para que pudesse prevalecer versão diversa, caberia à réu apresentar as provas capazes de embasar realidade distinta da que está sendo descortinada pela prova acusatória.

Tem-se, portanto, de um lado, as versões uniformes e harmônicas dos policiais e de outro lado a mera negativa do réu que não está obrigado a fazer prova contra si.

A dúvida capaz de favorecer o réu deveria estar sustentada em contraprovas e não meramente a partir de argumentações e negativa, sob pena de contemplar-se indevidamente a subjetividade e o "decisionismo".

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEI MALATESTA, o qual afirma que "o

princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 – destaque do Juízo).

Diante de tal panorama, não se ressentem este Juízo de qualquer dúvida razoável a respeito da procedência da ação penal, não sendo possível fundamentar o veredito com base em elementos diversos daqueles que vêm no sentido da tese acusatória.

Presente a tipicidade delitiva na forma capitulada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

3 -) DO VEREDITO E DOSIMETRIA DA PENA

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 103/104, para CONDENAR CARLOS HENRIQUE EFIGENIO FONSECA pela prática do crime capitulado no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, passando a dosar-lhe a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixa transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Na análise determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas tem-se que o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de 0,4 gramas de cocaína – pg. 145; 31,5 gramas de maconha – pg. 148 e 4,46 gramas de cocaína na forma de crack – pg. 151.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

A quantidade-massa é insuficiente para justificar qualquer acréscimo. Todavia, pela quantidade-diversidade impõe-se o acréscimo de 1/6 à reprimenda, eis que o réu tinha à sua disposição três tipos diferentes de drogas, demonstrando maior potencial para disseminar o nefasto vício entre "clientela" diversificada.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta

natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, no mínimo legal, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Presente a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, eis que o réu é menor de 21 anos. Embora o crime tenha sido praticado durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia COVID-19, o que poderia agravar a pena na forma da alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, mantenho a pena no patamar encontrado na primeira fase, diante da menoridade relativa. Noutras palavras, fica compensada a agravante com a atenuante.

Aplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que o réu é primário e a quantidade de entorpecentes não é suficiente para indicar ligação a organização criminosa.

Portanto, considerando que o réu é primário e a apreensão não possui dimensão suficiente para indicar que ele integra organização criminosa deve ser beneficiado com o redutor em seu patamar máximo.

Reduzo a pena em 2/3 fixando-a em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 195 dias-multa.

À míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena torno em DEFINITIVA a pena de supra.

Quanto ao regime prisional impõe-se prontamente reconhecer que na sessão do dia 23.06.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos.

O próprio Ministério Público não discordou. O parecer do subprocurador-geral da República Edson de Oliveira Almeida contém o seguinte trecho:

"A questão da hediondez do "tráfico privilegiado" está afetada ao Plenário (HC nº. 110.884/MS), aguardando julgamento. É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional (art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, e art. 83, V, do Código Penal). Contudo esses prazos maiores se aplicam apenas aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34 a 37 da Lei 11.343/2006, sem abranger as condutas punidas pelo § 4º do art. 33, que têm menor grau de reprovabilidade e, portanto, não podem ser qualificadas pela hediondez. Donde, condenados os pacientes por tráfico privilegiado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, o resgate de 1/6 e 1/3 da pena, para a progressão de regime e livramento condicional, a teor dos artigos 112 da Lei de Execução Penal e art. 83, inciso I, do Código Penal, respectivamente."

O Egrégio STJ revogou sua súmula 512 para acompanhar o entendimento do E. STF e tem reiteradamente concedido habeas corpus contra decisões do E. TJSP.

A propósito: Habeas Corpus nº 391.654/SP (2017/0052379-4), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 05.06.2017; Habeas Corpus nº 509.578/SP (2019/0133777-0), STJ, Rel. Antônio Saldanha Palheiro DJe 16.05.2019. Habeas Corpus nº 394.704/SP

(2017/0074889-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.05.2017; Habeas Corpus nº 386.049/SP (2017/0013012-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 19.05.2017.

Em caso análogo, ao apreciar a apelação nº. 0000032-53.2016.8.26.0613, a Colenda 2ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória proferida por este Juízo, mantendo igualmente a determinação de que o réu inicie o cumprimento da pena sob o regime aberto.

Também a 12ª Câmara Criminal no julgamento da Apelação nº 0000322-85.2016.8.26.0575 desta comarca manteve o regime inicial aberto com expressa alusão às Súmulas 718 do STF e Súmula 440 do STJ, bem como ao HC STF ° 118.533.

A 16ª Câmara Criminal seguiu o mesmo norte na Apelação nº 0001003-55.2016.8.26.0575 desta Comarca, em acórdão da Relatoria do Eminentíssimo Desembargador Guilherme de Souza Nucci.

O REGIME ABERTO também se mostra possível neste caso concreto diante da pequena quantidade de drogas, primariedade do réu e sua menoridade relativa. É o que fica fixado.

Inviável a substituição da pena, a despeito da resolução nº 5/2012 do Senado Federal. Neste ponto, anoto que malgrado o assentado, v.g, no HC. 101.291 – SP, relatado pelo Ministro Eros Grau no Supremo Tribunal Federal, cerro fileiras com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no incidente de arguição de inconstitucionalidade no habeas corpus nº 120.353 – SP, cujo relator é o Ministro Ari Pargendler, pois a individualização da pena é tarefa que incumbe primeiramente à lei e disso o legislador se desincumbiu engendrando a proibição citada no dispositivo invocado.

No mais, tenho por irretorquíveis os argumentos de Sua Excelência no sentido de que “se a lei deve assegurar indiscriminadamente ao juiz o arbítrio para, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, o próprio artigo 44 do Código Penal seria inconstitucional ao excluir desse regime os crimes cometidos à base de violência ou grave ameaça à pessoa – e com maior razão.”

Para este Juízo não se afigura socialmente recomendável a reinserção de traficantes ao convívio social indicando-lhes instituições públicas (escolas, asilos, centro de saúde, etc) para prestarem serviços comunitários. Ausente, portanto, o requisito do inciso III do art. 44 do Código Penal (suficiência da substituição).

Ademais, considera-se que o tráfico de drogas é crime que revela grave ameaça à sociedade, portanto, com maior razão, não poderia comportar a substituição por penas restritivas de direito.

No mesmo diapasão: Apelação nº 001224186.2010.8.26.0153, comarca de Cravinhos. Rel. Francisco Bruno, j. 16.06.2011; Apelação 990.09.063232-1, comarca de São José dos Campos. Rel. Newton Neves, j. 17.05.2011.

O descumprimento do regime aberto (adequado segundo o STF e STJ), por outro lado, pode prontamente ensejar o encarceramento por regressão ao semi-aberto e, posteriormente, até para o regime fechado.

Permito ao réu que recorra em liberdade, diante do regime prisional fixado nesta

sentença e também por força do artigo 59 da Lei de Drogas.

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ 22.04.03, p. 253).

Patrocinado por advogado dativo arbitro os honorários, conforme regras do convênio. Oportunamente, expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

- 1 -) Expeça-se mandado de prisão no regime aberto e guia de execução definitiva. Faculta-se ao réu apresentar-se diretamente em Juízo para a audiência admonitória que será "encaixada" na pauta regular, nos dias úteis, das 13:00 às 16:30 para a imposição das condições e advertências legais. A medida tem a finalidade de evitar a intervenção da polícia para o cumprimento do mandado de prisão, preservando o réu de eventuais intempéries que podem ocorrer de forma absolutamente excepcional em situações deste jaez;
- 2 -) Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;
- 3 -) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
- 4 -) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;
- 5 -) Decreto o perdimento dos valores apreendido R\$ 70,00, os quais serão revertidos em favor do FUNAD, à míngua de comprovação de origem ilícita a indicar que se trata do produto da traficância.

P.I.C

Sao Jose do Rio Pardo, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA